

1500176-77.2022.8.26.0439
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Fato Atípico
Magistrado: Luciano Correa Ortega
Comarca: Pereira Barreto
Foro: Foro de Pereira Barreto
Vara: Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 18/03/2022

... tal decisão, considerando que o tráfico é severamente punido – observação que realizou com maestria o ilustre ministro Edson Fachin: É paradoxo desassossegador perfilhar descriminalização do uso de drogas cuja produção e comercialização tipificam, ao mesmo tempo, o crime de tráfico. Isso porque se a retirada do estigma criminal permite que se dê a devida atenção ao bem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Pereira Barreto
Foro de Pereira Barreto
Juizado Especial Cível e Criminal
Rua Francisca Senhorinha Carneiro, S/N, Pereira Barreto - SP - cep 15370-000

1500176-77.2022.8.26.0439 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500176-77.2022.8.26.0439
Classe - Assunto
Termo Circunstanciado - Fato Atípico
Autor:
Justiça Pública
Autor do Fato:
THIAGO MUNIZ SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Correa Ortega

Vistos.

Relatório dispensado (art. 81, §3º, da Lei nº 9.099/95).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de denúncia oferecida tendo em vista a subsunção do réu ao disposto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, porque no horário e local mencionados na denúncia, tinha em depósito, para consumo pessoal, droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Revendo meu posicionamento anterior, entendo que não há presença de tipicidade material da infração penal prevista no Art. 28 da Lei de Tóxicos.

Inicialmente, calha ressaltar que há inúmeras polêmicas acerca do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Em julgamento do RE 635.659, alguns ministros do STF já se manifestaram pela inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei Antidrogas.

É fato que, num primeiro momento, parece incompatível tal decisão, considerando que o tráfico é severamente punido – observação que realizou com maestria o ilustre ministro Edson Fachin: É paradoxo desassossegador perfilhar descriminalização do uso de drogas cuja produção e comercialização tipificam, ao mesmo tempo, o crime de tráfico. Isso porque se a retirada do estigma criminal permite que se dê a devida atenção ao bem jurídico tutelado e ao tratamento do usuário, sempre conviver-se-á com o indelével gravame de vê-lo enredado no tecido criminoso de distribuição da

droga. A dependência é o calabouço da liberdade mantida em cárcere privado pelo traficante. Repito: a dependência é o calabouço da liberdade mantida em cárcere privado pelo traficante.

Filho-me ao entendimento da Colenda 6ª Câmara Direito Criminal, do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em Acórdão da lavra do Desembargador JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES TORRES, considerou-o inconstitucional.

Confira-se:

O artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é inconstitucional. A criminalização primária do porte de entorpecentes para uso próprio é de indisfarçável insustentabilidade jurídico-penal, porque não há tipificação de conduta hábil a produzir lesão que invada os limites da alteridade, afronta os princípios da igualdade, da inviolabilidade da intimidade e da vida privada e do respeito à diferença, corolário do princípio da dignidade, albergados pela Constituição Federal e por tratados internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil. (TJSP - Apelação Criminal nº 01113563.3/0-0000-000, 6ª Câmara Dir. Criminal, j. 31/03/2008).

Da brilhante fundamentação do v. Acórdão extrai-se que, transformar aquele que tem a droga apenas e tão-somente para uso próprio em agente causador de perigo à incolumidade pública, como se fosse um potencial traficante, implica em frontal violação do princípio da ofensividade, dogma garantista previsto no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal.

Isso porque, precipuamente, a conduta do agente que porta drogas para seu consumo, invade tão somente a sua esfera pessoal, além de que, a sanção para tal conduta é inofensiva a ponto de banalizar o direito penal, o qual não deve cuidar de condutas bagatelaes ou ínfimas, mas tão somente aquelas que realmente lesionem o bem jurídico tutelado. Portanto, conclui-se, nesta perspectiva, procedendo-se à aferição da periculosidade ou ofensividade da conduta e seu desvalor social, que há ausência de qualquer lesividade desta conduta de consumo de entorpecentes, eis que ela não constitui fato penalmente relevante, porque, atingindo a esfera meramente pessoal do próprio consumidor, não vulnera seriamente a ordem jurídica.

Além disso, a criminalização do porte para uso próprio também viola o princípio constitucional da igualdade, pois há flagrante "distinção de tratamento penal (drogas ilícitas) e não-penal (drogas lícitas) para usuários de diferentes substâncias, tendo ambas potencialidade de determinar dependência física e psíquica" (Salo de Carvalho, A política criminal de drogas no Brasil. Estudo criminológico e dogmático, Editora Lumen Juris, RJ, 2007, p. 253).

No mais, a quantidade de entorpecentes encontrada com o réu foi ínfima, de modo que, passível a incidência do princípio da insignificância.

Destaco à luz do princípio da insignificância os seguintes julgados:

"Entorpecente. Quantidade ínfima. Atipicidade. O crime, além da conduta, reclama um resultado no sentido de causar dano ou perigo ao bem jurídico (...); a quantidade ínfima informada na denúncia não projeta o perigo reclamado".1 Sempre "é importante demonstrar-se que a substância tinha a possibilidade para afetar ao bem jurídico tutelado". A pena deve ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Quando a conduta não seja reprovável, sempre e quando a pena não seja necessária, o juiz pode deixar de aplicar dita pena. O Direito penal moderno não é um puro raciocínio de lógica formal. É necessário considerar o sentido humanístico da norma jurídica. Toda lei tem um sentido teleológico. A pena conta com utilidade" (decisão de 21.04.1998, relator LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, DJU de 17.08.1998, p. 96.).

Penal. Entorpecentes. Princípio da insignificância. - sendo ínfima a pequena quantidade de droga encontrada em poder do réu, o fato não tem repercussão na seara penal, à míngua de efetiva lesão do bem jurídico tutelado, enquadrando-se a hipótese no princípio da insignificância - habeas corpus concedido (STJ, HC 17956-SP, rel. Min. Vicente Leal)".

Não bastasse a circunstância da quantidade do estupefaciente, a tornar atípica a conduta, como acima visto, penso, sobretudo tendo em vista a despenalização da figura típica, conforme se verifica no art. 28 da Lei 11.343/06, que a conduta do

consumo de entorpecentes não constitui fato penalmente relevante, porque, se a sanção para tal conduta é tão ínfima, como se verifica, pode-se constatar a forte presença de um direito penal promocional, cuja maior preocupação é apaziguar a sensação social de impunidade, deixando de ser o direito penal como um modo de controle social subsidiário (ultima ratio), incompatível com um Estado de direito em que vige o princípio da fragmentariedade, o qual dispõe que apenas as condutas humanas mais graves e relevantes, que realmente lesem o bem jurídico tutelado, devem ser protegidas pelo direito penal; ora, se a conduta de porte para o consumo pessoal é tão irrelevante a ensejar sanções igualmente e demasiadamente irrelevantes, não há que se falar em tipicidade desta conduta.

Isso porque, para se consolidar como um adequado instrumento de tutela aos bens jurídicos mais relevantes para o sistema, promovendo efetivamente a prevenção delitiva geral e especial, afastando-se da ideia de um direito penal simbólico, o direito penal deve intervir nas relações sociais apenas quando determinada conduta atinja o bem jurídico de modo intolerável, intervenção esta que deve cumprir sua finalidade, qual seja, proteger o bem jurídico supostamente lesionado. E, no caso do Art. 28 da Lei 11.343/06, não se vislumbra qualquer proteção ao bem jurídico tutelado (saúde pública) com a criminalização da conduta lá tipificada.

Outrossim, não se vislumbra, conforme já explanado anteriormente, efetiva lesividade da conduta. Destaco a propósito o voto do Desembargador Nereu José Giacomolli, que ainda ao tempo do art. 16 da Lei 6368/76, bem enfocou a questão: "O princípio da ofensividade ao bem jurídico, como afirma Luiz Flávio Gomes (Princípio da Ofensividade no Direito Penal, p. 25), há de ser instrumentalizado e tornado efetivo, sob pena de se ter um discurso liberal e uma aplicação autoritária do Direito Penal. Como bem ensina Carbonell Mateu (Derecho Penal: Concepto y Principios Constitucionales, 1999, p. 215-218), o princípio da ofensividade ou lesividade exige que não haja crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico, dentro de um critério valorativo que a norma comporta. Mais, num Estado Social e Democrático de Direito, a intervenção punitiva somente se justifica nas condutas transcendentais aos demais que atinjam as esferas de liberdade alheias, sendo contrário ao princípio da ofensividade o castigo de uma conduta imoral, antiética ou antiestética que não invada a liberdade alheia. Ainda, este princípio descansa na consideração do crime como um ato desvalorado, isto é, contrário à norma de valorização" (TJRS - RJTJRGs 240/74 - Rec. 70013554571 - j. 18.05.2006 - RJTJRGs 257/197 e Ap. 70008849051 - j. 26.08.2004).

Prudente enfatizar que, até mesmo ao tempo da lei 6368/76 havia outros entendimentos jurisprudenciais no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo que consideravam atípica a conduta do porte de entorpecente, conforme pode se verificar a seguir:

"O legislador sanciona a aquisição, a guarda e o porte do entorpecente para uso próprio, entendendo que 'o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo porque é fator decisivo na difusão do tóxico. No entanto, a partir do momento em que a consome, lesa a si próprio e sua conduta não representa mais um perigo social' (Ap. 168.697, TACRIM).

Com efeito, falta lesividade ao tipo penal e sem ela não atua o Direito Penal, pois, na lúcida observação de Claus Roxin, "o legislador, mandatário do povo, tem sua tarefa limitada à proteção do indivíduo dos ataques dos outros e a assegurar uma vida mais livre possível e de maior bem-estar possível, e nada tem a ver com tal tarefa o tutelar moralmente cidadãos adultos contra sua vontade" (Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal. Trad. cast. Barcelona, 1989, p. 22)" (TJSP - Ap. - Rel. Dante Busana - JTJ 168/321).

Nesta esteira, discorrendo sobre o art. 28 da Lei de Tóxicos, Luiz Flávio Gomes, e Alice Bianchini sustentam que "houve descriminalização formal (acabou o caráter criminoso do fato) e, ao mesmo tempo, despenalização (evitou-se a pena de prisão para o usuário de droga). O fato (posse de droga para consumo pessoal) deixou de ser crime (formalmente) porque já não é punido com reclusão ou detenção" (art. 1º da LICP) e concluem que se trata de uma "infração penal sui generis" (GOMES, Luiz Flávio e BIANCHINI, Alice. Usuário de drogas: a polêmica sobre a natureza jurídica do art. 28 da Lei 11.343/06. Disponível em: <http://www.lfg.blog.br>. 12 mar. 2007).

No mais, o Art. 28 da Lei de Tóxicos fere o princípio da alteridade, mandado de otimização o qual impede a incriminação de conduta que prejudica somente ao agente, ou seja, proíbe a incriminação de ações internas e que só digam respeito ao próprio indivíduo. Neste sentido, se as ações do indivíduo limitam-se apenas ao seu interior, não transcendendo ao ambiente externo, e por consequência não ferindo, prejudicando ou lesando interesses de outrem, impossível a aplicação do “jus puniendi” (direito de punir pelo Estado).

Justamente por isso, o ordenamento jurídico pátrio vigente não pune a conduta de tentativa de suicídio, por exemplo. E, neste viés, não há razão de se criminalizar a conduta de porte de drogas para consumo, a qual só prejudica aquele que as utiliza, não se justificando uma intervenção repressiva do Estado.

Na discussão em andamento no Supremo, o Ministro Edson Fachin asseverou: A interpretação do Direito Penal à luz da Carta da República tem sentido a partir de duas premissas básicas: a diferenciação entre penas e medidas de segurança, e a exigência de expressa previsão constitucional, para justificar a limitação de direitos fundamentais. A primeira premissa indica que, em situações excepcionabilíssimas, é possível atribuir a qualidade de perigo a determinada pessoa. Por isso, exceto nas situações em que o desenvolvimento bio-psico-social afaste a culpabilidade, a separação entre penas e medidas de segurança jamais autorizaria fazer recair sobre a pessoa do agente o juízo de condenações.

Já neste ponto é possível antever que a incriminação da drogadição situa-se na tênue delimitação entre o Direito Penal do autor e o do fato. Com efeito, a posse para uso pessoal, embora tipifique a ação, incide sobre conduta que, não raro, é condição essencial da pessoa, e a vetor constitucional que não autoriza a penalização da personalidade.

No que tange às limitações dos direitos fundamentais, é preciso que eventual restrição encontre fundamentação constitucional. Nessa diretriz, alberga-se o princípio da tipicidade, a exigir reserva de lei para normas penais. Considerando que a tipicidade decorre da teoria sobre os direitos fundamentais, ao legislador não compete apenas observar a reserva de lei para tipificar determinada conduta, como também deve demonstrar que pela incriminação outro direito fundamental será protegido.

A doutrina costuma indicar que a sede do princípio da ofensividade como parâmetro de controle de constitucionalidade reside no art. 98, I, da Constituição da República. Embora a referência tópica possa constar desse dispositivo, o conteúdo do princípio decorre, de um lado, da opção constitucional e legal por um Direito Penal orientado por fatos; e, de outro, da impossibilidade de se criminalizar condutas que não atinjam um fundamento constitucionalmente assegurado.

Nesse sentido, é correto afirmar que o princípio da ofensividade tem assento constitucional e serve de parâmetro para o controle da atividade do Legislativo. Esse controle não incide, entretanto, indistintamente sobre todas as normas penais, nem sobre os objetivos e motivações invocados para edição da norma, pois, em tais circunstâncias, seria preciso recorrer-se a argumentos consequencialistas, para afastar a prerrogativa de avaliação feita pelo Legislativo. O princípio da ofensividade permite, de fato, a limitação do próprio direito, mas não autoriza que se oponham argumentos utilitários à validade normativa.

Essa tarefa tem ainda maior importância se o reconhecimento da extensão dos bens jurídicos e da consequente proteção estatal for medida em relação à eventual restrição da liberdade. Nesse sentido, caberia à teoria do bem jurídico identificar quais bens podem justificar a restrição à liberdade.

Não se trata, contudo, de afastar a priori qualquer pretensão de permitir ao Estado perseguir fins morais. Ao contrário, inexistente um princípio que delimite a esse ponto a atividade estatal regulatória. É preciso registrar, neste particular, que a possibilidade de se buscar fins morais não é descontextualizada: apenas em sociedades em que haja o respeito à autonomia dos cidadãos, garantindo-lhes um amplo espectro de opções valorosas (RAZ, Joseph. *The Morality of Freedom*. Oxford: Oxford University Press, 1986), é que seria possível falar em uma larga margem de avaliação para estabelecer fins morais.

O ponto de partida para se delimitar o campo de restrição à autonomia parece estar

no princípio da ofensividade: somente havendo dano efetivo, porquanto haveria, por conseguinte, uma interferência na autonomia das outras pessoas, é que se pode legitimar a coerção.

A sanção penal é, assim, tão-só uma das formas de se proteger os bens jurídicos. Consubstanciando a mais grave restrição na autonomia dos cidadãos, cumpre, portanto, avaliar se ela é adequadamente posta. E é aqui que tem assento a proporcionalidade.

Especificamente em relação à coerção penal, poder-se-ia apontar, na linha do que indica Claus Roxin, serem ilegítimas as incriminações de: motivações ideológicas; autolesão; tabus; fins extrapenais; e abstrações incapazes de constituir bens jurídicos (ROXIN, Claus. *Es la protección de los bienes jurídicos una finalidad del derecho penal?* In: *La teoría del bien jurídico. Fundamentos de legitimación del derecho penal o juego de laboratorios dogmáticos?* Roland Hefendehl (ed.). Barcelona: Marcial Pons, 2007).

Essas considerações parecem indicar que, em vista da ofensa a um bem individual, não se pode dar ensejo à criminalização. Esse norte tem sentido especialmente para o adicto, usuário dependente de droga; impende ajudar o usuário que queira se livrar do poder criminoso da dependência. Frise-se, relativamente a esta inferência, que não se visa inviabilizar a atividade regulatória do Estado, nem mesmo a de imposição de sanções, mas a afastar que a regulação seja feita por meio da coerção penal como primeiro antídoto.

Em seu voto, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim ponderou:

Na valoração da importância de determinado interesse coletivo como justificativa de tutela penal há de se exigir a demonstração do dano potencial associado à conduta objeto de incriminação. Em outras palavras, há que se verificar em que medida os riscos a que sujeitos os interesses coletivos podem justificar a conversão destes em objeto de proteção pelo direito penal. Conforme observa PUIG, o Estado Social não pode desconhecer, [na definição de crimes de perigo abstrato], a significação que, por si mesma, implica a extensão social de um determinado interesse e tampouco há de prescindir da exigência de um mínimo de repercussão do interesse coletivo em relação a cada indivíduo. Acredita o autor ser essa a via adequada se se pretende evitar a hipertrofia do direito penal (PUIG, Santiago Mir, "Concepto de Bien Jurídico-Penal como Limite del Ius Puniedi", *Estudios de Derecho Penal, Processual e Criminologia em Homenagem ao Prof. Dr. Kurt Maldlener*, coordenadores Adhemar Ferreira Maciel et alii. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciário, 2014). E exemplifica justamente com o direito à saúde pública. Não cabe negar, afirma o autor, que a saúde pública é um interesse coletivo que afeta cada indivíduo, mas há que se exigir um determinado grau de lesividade individual para que se possa justificar a intervenção do direito penal. Até agora não se tem afirmado, por exemplo, que o álcool e o tabaco afetam suficientemente a saúde pública a ponto de legitimar a criminalização de sua venda e consumo. Em relação ao tabaco, observa que a proteção da ordem pública coletiva tem sido alcançada com o incremento da proibição de seu consumo em lugares públicos, porém por meio de medidas administrativas. O mesmo raciocínio, ainda segundo PUIG, aplica-se em relação às drogas. Sustenta ser preciso diferenciar as drogas quanto a seus distintos efeitos em relação a cada indivíduo. Além disso, há que se ter em conta que a lesividade individual vem, neste caso, acompanhada do consentimento da vítima. Dessa forma, a prevenção do uso indevido de drogas, um dos princípios do sistema nacional de políticas públicas sobre drogas – art. 4º da Lei 11.343/06 – é uma finalidade estatal válida e pode ser alcançada, com maior eficácia, por meio de um vasto leque de medidas administrativas. Nesse contexto, a criminalização do porte de drogas para uso pessoal afigura-se excessivamente agressiva à privacidade e à intimidade. Além disso, o dependente de drogas e, eventualmente, até mesmo o usuário não dependente estão em situação de fragilidade, e devem ser destinatários de políticas de atenção à saúde e de reinserção social, como prevê nossa legislação – arts. 18 e seguintes da Lei 11.343/06. Dar tratamento criminal a esse tipo de conduta, além de andar na contramão dos próprios objetivos das políticas públicas sobre o tema, rotula perigosamente o usuário, dificultando sua inserção social. A situação ainda é mais grave pela prevalência do consumo de

drogas entre os jovens, pessoas em fase de desenvolvimento da personalidade e definição de vida e, por isso, especialmente sensíveis à rotulação decorrente do enquadramento criminal. Da mesma forma, a percepção geral é de que o tratamento criminal aos usuários de drogas alcança, em geral, pessoas em situação de fragilidade econômica, com mais dificuldade em superar as consequências de um processo penal e reorganizar suas vidas depois de qualificados como criminosos por condutas que não vão além de mera lesão pessoal. Assim, tenho que a criminalização da posse de drogas para uso pessoal é inconstitucional, por atingir, em grau máximo e desnecessariamente, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, em suas várias manifestações, de forma, portanto, claramente desproporcional.

Neste sentido, resta claro, inclusive, que o tipo penal previsto no Art. 28 da Lei de Tóxicos viola, não só o princípio da alteridade, considerando-se também que sequer ostenta aptidão para proteger os bens jurídicos declarados como tutelados, quais sejam, a saúde e segurança pública, mas também viola o direito à privacidade e intimidade, os quais devem ensejar ações negativas de abstenção do Estado, nos termos da Carta Magna.

Por fim, ressalte-se decisões atuais do STJ, que não mais consideram as condenações pelo disposto no artigo 28 da Lei Antidrogas para fins de reincidência: 4. Contudo, as condenações anteriores por contravenções penais não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o art. 63 do Código Penal, que apenas se refere a crimes anteriores. E, se as contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostra-se desproporcional o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 configurar reincidência, tendo em vista que nem é punível com pena privativa de liberdade. 5. Nesse sentido, a Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.672.654/SP, da relatoria da Ministra MARIA THEREZA, julgado em 21/8/2018, proferiu julgado considerando desproporcional o reconhecimento da reincidência por condenação pelo delito anterior do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. (HC 453.437/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018).

Em suma, haveria um crime “despenalizado”, com penas que não possibilitam a prisão, incapaz de gerar reincidência, desafeito à alteridade.

Ante o exposto, ressaltando que atípico, a meu ver, o fato, REJEITO A DENUNCIA e absolvo o réu sumariamente, nos termos do artigo 397, III, do Código de Processo Penal.

Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos e restituição de eventuais valores apreendidos, desde que estritamente relacionados ao artigo 28, da Lei Antidrogas, expedindo-se o necessário, nos termos do que preconizam as Normas da Corregedoria.

Feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos.

Int. Cumpra-se.

P.I.C.

Pereira Barreto, 17 de março de 2022.